

1500734-71.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... da venda espúria. A ré confessou o tráfico de drogas. Não reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, pois a escola ficava há uns 400 metros da escola (fls. 8/9), não havendo certeza de que o tráfico ocorria nas suas imediações de um estabelecimento estudantil ou que alunos da escola passassem por aquele local. Portanto, pelas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500734-71.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2084869/2021 - 02º D.P. MAUA, 17018314 - 02º D.P. MAUA, 309/21/125 - 02º D.P. MAUA, 309/2021 - 2º Distrito Policial de Mauá, 2084869 - 02º D.P. MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NAYARA LIMA SENA

Data da Audiência:

29/08/2022

Em 29 de agosto de 2022 às 14h10, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de ré privada de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, a acusada e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr.

Ricardo Flório. Presente a ré Nayara Lima Sena, notificada e citada em audiência. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas comuns Severino de Moraes e Douglas Anderson Dias. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi decidido: "1) Diante da prisão da acusada (fls. 146/149), indicando o fim da situação excepcional prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal, determino a retomada do andamento destes autos. Procedam-se as anotações e expeçam-se as comunicações necessárias. 2) A ré foi notificada e citada em audiência e a defesa ratificou a defesa prévia de fls. 125/126. 3) Dada ciência ao Ministério Público dos documentos juntados pela defesa (fls. 168/172) e não havendo oposição pela acusação, defiro a juntada dos documentos, nos termos do artigo 231 do Código de Processo Penal. A seguir, foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com a acusada antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogada a ré. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. NAYARA LIMA SENA, qualificada às 12 e 16, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 26 de março de 2021, por volta das 11h:20min, na Rua Fernando Colombo, nº 118, Jardim Salgueiro, nesta cidade e comarca de Mauá, trazia consigo e guardava, para entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 57 invólucros de cocaína, com peso líquido de 42,87g, e 65 invólucros de maconha, com peso líquido de 129,4g, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, laudo de constatação de fls. 26/29, e laudo químico-toxicológico de fls. 67/69 (fls. 73/74). Foi concedido a acusada os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 45/46). A denúncia foi oferecida (fls. 72). A ré foi notificada por edital (fls. 119) e apresentou defesa preliminar (fls. 125/126). A denúncia foi recebida (fls. 127). O processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, sendo revogada a liberdade provisória e decretada a prisão preventiva da ré (fls. 138/140). A ré foi presa (fls. 146/149) e foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 152/156). A ré foi notificada pessoalmente e citado pessoalmente em audiência e a defesa ratificou a defesa preliminar que já havia sido apresentada (termo de audiência e fls. 125/126). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Severino de Moraes (gravação audiovisual) e Douglas Anderson Dias (gravação audiovisual), e por fim, procedeu-se o interrogatório da ré Nayara Lima Sena (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Severino de Moraes (fls. 5/6) e Douglas Anderson Dias (fls. 7) e a ré Nayara Lima Sena (fls. 10). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação da ré e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa da ré Nayara, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade, o reconhecimento da causa de diminuição

prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Printscreen do aplicativo Google Maps (fls. 8/9). Foto da ré (fls. 15). Auto de exibição e apreensão (fls. 22/23). Fotos das drogas (fls. 24). Laudo de constatação provisória (fls. 26/29). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 67/69). Laudo de exame na pochete (fls. 104/106). Folha de antecedentes (fls. 80) e certidão (fls. 33/34). II - Fundamentação. A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), printscreen do aplicativo Google Maps (fls. 8/9), foto da ré (fls. 15), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), fotos das drogas (fls. 24), laudo de constatação provisória (fls. 26/29), exame químico toxicológico definitivo (fls. 67/69), laudo de exame na pochete (fls. 104/106) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a testemunha Severino de Moraes disse que: a) houve uma ligação anônima para a investigação e moradores deste lugar onde foi abordada a Nayara alegaram que ali havia mercância de entorpecentes, mesmo tendo flagrante uns dias antes ali; b) eu e o Douglas entramos, cada um por um lado da viela; c) eu encontrei a Nayara com uma pochete, perguntei a ela se tinha maconha, ela disse que sim, daí eu disse que era policial e na pochete havia maconha e cocaína, 100 e poucas porções, além de R\$ 60,00 e poucos reais; d) ela disse que o menor deu a pochete para ela para ficar uns minutos para ele tomar café e ela receberia uma porção de maconha; e) entre 300 a 400 há uma escola municipal, cujo nome não me recordo; f) não sei se estava tendo presenciais; g) não conhecia ela (gravação audiovisual e fls. 5/6). A testemunha Douglas Anderson Dias, sob o crivo do contraditório, disse que: a) o meu colega recebeu uma denúncia anônima de que havia o tráfico de entorpecentes no local; b) o local já era conhecido pela gente; c) quando o meu colega chegou, ela estava com a pochete; d) na pochete havia 100 e poucos invólucros de entorpecentes, entre maconha e cocaína e R\$ 60,00 e poucos reais; e) a pochete estava com ela, segundo o meu colega; f) quando eu cheguei ao local ela já estava abordada pelo meu colega; g) ela disse que era dependente química, ela conhece as pessoas que comercializam e ela disse que ficaria lá, enquanto o traficante for tomar café, mas ela estava com a pochete para vender drogas; h) há uma escola municipal há centena de metros; i) não sei se as aulas presenciais já haviam retornado; j) não conhecia a ré; k) a escola ficava de 300 a 400 metros do local (gravação audiovisual e fls. 7). Por fim, o réu Nayara Lima Sena, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos são verdadeiros; b) eu fui comprar para o meu uso; c) a pessoa que estava no dia, a pessoa pediu para eu ficar lá; d) eu não faço mais essas coisas para não ter mais contato com essas pessoas; e) eu estava com a pochete nas minhas mãos e estava vendendo as drogas; f) era maconha e cocaína; g) eu não me recordo quanto dinheiro havia, acho que era R\$ 60,00 ou coisa assim; h) a escola era um pouquinho longe, ela ficava há uns 5 quarteirões; i) eu estou muito arrependida, fui morar com a minha família e me inscrevi na escola; j) eu não sabia que estava sendo procurada; k) não estava tendo aula, porque estava na época do COVID; l) eu tentei atualizar o meu endereço várias vezes, mas eu tinha que voltar lá para ver quando estaria aberto (gravação audiovisual e fls. 10). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), printscreen do aplicativo Google Maps (fls. 8/9), foto da ré (fls. 15), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), fotos das drogas (fls. 24), laudo de constatação provisória (fls. 26/29), exame químico toxicológico definitivo (fls. 67/69), laudo de exame na pochete (fls. 104/106), como também

pelos depoimentos das testemunhas Severino de Moraes (gravação audiovisual e fls. 5/6) e Douglas Anderson Dias (gravação audiovisual e fls. 7), e pela confissão d ré Nayara Lima Sena (gravação audiovisual e fls. 10), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais civis, foram ate o local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, onde a ré tinha uma pochete vermelha que continha 57 porções de cocaína, pesando 42,87g, e 65 porções de maconha, pesando 129,4g, além de R\$ 64,00, decorrente da venda espúria. A ré confessou o tráfico de drogas. Não reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, pois a escola ficava há uns 400 metros da escola (fls. 8/9), não havendo certeza de que o tráfico ocorria nas suas imediações de um estabelecimento

estudantil ou que alunos da escola passassem por aquele local. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação da ré Nayara Lima Sena, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (57 porções de cocaína, pesando 42,87g, e 65 porções de maconha, pesando 129,4g - fls. 22/23, 26/29 e 67/69) não permitem aumentar a pena, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a ré (fls. 33/34 e 80). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravante a ser apreciada. Deixo de reduzir a pena da ré, pela sua confissão (gravação audiovisual e fls. 10) e era menor de 21 anos na data dos fatos (fls. 9 e 12), porque ela se encontra no mínimo legal, segundo dispõe o artigo 67 do Código Penal e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas aumento de aumento de pena. Reduzo a pena em 2/3, passando para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade das drogas, para fins de obstar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP, passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação da pena. Outrossim, não há outro critério para a redução da pena entre 1/6 e 2/3, a não ser a natureza e a quantidade das drogas, mas, como já dito, ela não pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3, pois, não havendo outro critério a ser utilizado, e não há, o juiz não poderia quantificar a pena a seu bel-prazer, pois agindo assim estaria violando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Inclusive, nos processos nos 1500527-09.2020.8.26.054 (fls. 318/325) e 1501072-79.2020.8.26.0540 (fls. 426/435), que tramitam nesta Vara, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça que este magistrado recalculasse a pena com base nestes parâmetros. Desta maneira, por segurança das relações jurídicas, passo a dosar a pena, conforme a mencionada orientação dos Tribunais Superiores. No caso do tráfico de drogas, o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 determina que o juiz "na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" - (grifei). Ou seja, a fixação da pena compreende a dosimetria e o regime inicial de cumprimento, tanto que o legislador ressaltou que a natureza e a quantidade das drogas e a conduta social preponderam sobre o artigo 59 do Código de Processo Penal, e este artigo (59 do Código de Processo Penal) deve ser considerado na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme prevê o artigo 33, § 3º, do Código de Processo Penal. Desta maneira, fixo o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, a despeito de a pena ser inferior a quatro anos e a ré não ser reincidente (fls. 33/34 e 80), a natureza e quantidade das drogas apreendidas (57 porções de cocaína, pesando 42,87g, e 65 porções de maconha, pesando 129,4g - fls. 22/23, 26/29 e 67/69), preponderam sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, e o artigo 59 do Código Penal deve ser levado em consideração na dosimetria da pena, segundo preceitua o artigo 33, § 3º, do Código Penal. Neste sentido a jurisprudência: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENA E RECUSA DE ENVIO À PGJ. RECUSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO PARQUET. ANUÊNCIA DO MAGISTRADO. PROPOSTA DE REVISÃO REQUERIDA A DESTEMPO PELA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA

WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe de 3/4/2018. 2. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 4. Conforme o acórdão ora impugnado, o requerimento de revisão do não oferecimento de proposta do ANPP, para fins de análise do órgão superior do Ministério Público local, ocorreu a destempesto pela defesa, deixando que a instrução criminal fluísse regularmente. 5. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. No caso, embora estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (16 porções de maconha, pesando 66,2 gramas; 44 porções de cocaína, pesando 39,6g; 33 porções de crack, pesando 7,1g; - 13/16 e 70/71) , utilizadas na escolha do patamar de diminuição do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, o semiaberto, em razão da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos. 7. Habeas corpus não conhecido." - (grifei). (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte a quo afastou a aplicou a minorante considerando as circunstâncias fáticas da causa, qual seja, a quantidade e variedade das drogas apreendidas. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. A quantidade e natureza das drogas apreendidas - 116 porções de maconha- constituem fundamentos idôneos para o agravamento

do aspecto qualitativo da pena, ou seja, para a fixação de regime mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Tendo a reprimenda ultrapassado os 4 anos de prisão, a circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga) justifica a fixação do regime inicial semiaberto, segundo a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo

regimental desprovido." - (grifei). (AgRg no AREsp 1671723/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. III - Ademais, a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta requer fundamentação específica, baseada em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. IV - No caso, aplicada a pena de 2 anos de reclusão, entendo que deve ser estabelecido o regime inicial intermediário, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, e do art. 42 da Lei de Drogas. A quantidade e variedade dos entorpecentes podem ser utilizadas como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. V - O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC n. 97.256/RS, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, passou a admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. VI - Na hipótese em análise, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (16 porções de maconha, pesando 66,2 gramas; 44 porções de cocaína, pesando 39,6g; 33 porções de crack, pesando 7,1g; - 13/16 e 70/71) não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. Habeas corpus não conhecido. Ordem de ofício apenas para fixar o regime semiaberto para resgate da reprimenda, mantido os demais termos da condenação." - (grifei). (HC 581.356/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO ADEQUADO. AFASTAR CARÁTER HEDIONDO. PLEITO PREJUDICADO. DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Concluído pelas instâncias antecedentes, com fulcro nos elementos constantes dos autos e no fato de registrar atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 4. Embora o agente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento das sanções impostas, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza de

entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 6. Fica prejudicado o pleito de afastamento do caráter hediondo do delito, pelo não reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado. 7. Noticiado o trânsito em julgado da ação penal, caberá ao Juízo de execução penal averiguar a possibilidade de estabelecimento de regime mais brando diante do desconto do período em que o agravante permaneceu preso preventivamente. 8. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) - (grifei). Não substituo a pena da ré, porque, nos termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal, não é socialmente recomendável, pela natureza e quantidade das drogas (57 porções de cocaína, pesando 42,87g, e 65 porções de maconha, pesando 129,4g - fls. 22/23, 26/29 e 67/69), fato concreto que impede a substituição. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter a ré capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 13). A pochete (fls. 22/23) foi utilizada para a prática do crime de tráfico de drogas, porque as drogas estavam acondicionadas no seu interior (fls. 2/4, 22/23 e 26/29), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexo de instrumentalidade entre elas e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito não foi reclamado por qualquer terceiro de boa-fé, que deveria comprovar a sua propriedade, mormente porque a posse dos bens móveis se opera mediante simples tradição. Contudo, determino que o objeto seja destruído, devido ao seu valor irrisório, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei nº 11.343/2006. Igualmente, determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 22/23), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 22/23, 26/29 e 67/69). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO a ré NAYARA LIMA SENA (R.G. nº 54.659.395 - filha de Maria Eugenia Lima Sena - fls. 12 e 16), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 188 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo à ré o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva, porque o réu somente foi preso, porque não foi localizado (fls. 45/46, 49/50, 138/140 e 141/143), portanto como a instrução foi encerrada, não remanesce, por ora, necessidade da custódia cautelar da ré. Contudo, a ré deverá manter atualizado o seu endereço, sob pena de poder ser revogada a sua liberdade provisória. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor. A ré arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas a isento em virtude de estar sendo representada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial competente para que proceda a destruição do objetos apreendido; b) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; c) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; d) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; e) lance-se o nome da ré no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; f) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam

o desejo de recorrer da Sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido

pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.